

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제02절 소송요건>  
[예상][5.02-1]부제소특약의 간과와 본안기각판결 선고의 적법성 및 그 효력

《【문제5.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송 계속 중, 피고 乙은 甲과 소를 제기하기 전에 이미 이 사건 분쟁에 대하여 법원에 소를 제기하지 않기로 합의(부제소특약)를 하였으므로 이 사건 소는 부적법하다고 주장하며 소각하를 청구하였다. 그러나 제1심 법원은 부제소특약의 존재 여부 및 그 적법성에 대해 구체적으로 심리하지 아니한 채, 변론기일을 열어 곧바로 대여금 채권의 성립 여부 등 본안에 관한 심리를 진행하였다. 제1심 법원은 심리 결과 대여금 채권이 시효로 소멸하였다는 이유로 甲의 청구를 기각하는 본안판결을 선고하였고, 甲은 이에 불복하여 항소하였다. 한편, 또 다른 사건에서 원고 A는 피고 B를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하여 심리가 진행 중이다. 그런데 소송 계속 중 B는 A가 정신적 질환으로 인해 의사능력을 완전히 상실하였으므로 당사자능력에 흠결이 발생하였다고 주장하였다. 제1심 법원은 이러한 당사자능력과 같은 소송요건의 존재 여부를 어느 시점을 기준으로 판단해야 하는지, 그리고 해당 소송요건의 존부에 대한 증명책임은 소송법상 누구에게 귀속되는지 검토하고 있다.

(물음1) 피고 乙이 부제소특약의 합의가 존재한다고 주장하였음에도 제1심 법원이 소송요건의 존부를 판단하지 않고 본안기각판결을 선고한 조치의 적법성 여부를 소송요건의 조사 순서 및 소송요건 흠결을 간과한 판결의 효력과 관련하여 설명하시오.》

<문제5.2의 물음1> 부제소특약의 간과와 본안기각판결 선고의 적법성 및 그 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였는데, 乙이 부제소특약의 존재를 주장하였음에도 제1심 법원은 이에 대한 심리 없이 본안에 관하여 청구기각판결을 선고한 상황이다. 쟁점으로 <소송요건인 부제소특약의 존부를 본안에 앞서 심리하여야 하는지, 이를 간과한 채 선고한 본안판결의 적법성과 효력>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송요건의 조사 순서와 소송요건 흠결을 간과한 본안판결의 효력을 중심으로 제1심 법원의 조치의 적법성 여부를 설명한다.

II. 소송요건의 의의와 조사 순서

1. 소송요건의 의의와 부제소특약

(1) 소송요건의 의의

- 소송요건이란 소송이 적법한 상소로서 법원의 본안심판을 받기 위해 갖추어야 할 요건을 말한다. 이는 공익적 견지에서 법원이 직권으로 조사해야 하는 직권조사사항과 당사자의 이익이 있어야 비로소 조사하는 항변사항으로 나뉜다.

(2) 부제소특약의 성격

- 부제소특약은 당사자 간의 합의로 소송을 제기하지 않기로 약정하는 사법상 계약이다. 판례는 이를 권리보호의 이익(소의 이익)에 관한 소송요건으로 보며, 당사자가 주장해야 비로소 심리하는 소송법상의 항변사항으로 취급한다.

2. 소송요건의 조사 순서와 선순위성

(1) 조사 순서의 원칙

- 법원은 소가 적법한지(소송요건)를 먼저 심사한 후, 비로소 청구가 이유 있는지(본안)를 심리하여야 한다. 이를 소송요건심리의 선순위성이라고 한다. 소송요건이 구비되지 않은 소송은 부적법하므로 법원은 본안심리를 진행할 수 없다.

(2) 원칙의 위반 효과

- 소송요건에 흠결이 있는 소송에 대하여 본안판결을 선고하는 것은 소송요건심리의 선순위성 원칙에 반하여 허용되지 않는다. 즉, 소송요건에 대한 판단을 생략한 채 본안심리를 진행하여 판결하는 조치는 절차법적으로 부적법하다.

III. 소송요건 흠결을 간과한 판결의 효력

1. 간과판결의 효력 일반

(1) 당연무효 여부

- 소송요건의 흠결을 간과한 판결은 원칙적으로 당연무효가 아니다. 판결에 중대한 법령 위반이 존재하여 위법할 뿐이므로, 상소 제기를 통해 취소할 수 있는 사유(취소사유)에 불과하다. 만약, 상소기간이 경과하여 판결이 확정된다면 그 기판력 등의 효력은 그대로 유지된다.

(2) 예외적인 당연무효 사유

- 당사자능력이 원천적으로 결여된 사망자를 상대로 한 판결이나 대한민국 재판권이 미치지 않는 대상에 대한 재판 등 극히 이례적인 절차적 흠결이 존재하는 경우에 한하여 예외적으로 당연무효가 된다. 사안의 부제소특약 흠결은 이에 해당하지 않는다.

2. 항소심의 처리와 불이익변경금지의 원칙

(1) 항소법원의 조치

- 원고만이 항소한 경우, 항소심 법원은 제1심의 본안기각판결을 취소하고 소송요건 흠결을 이유로 소각하판결을 선고할 수 있다. 소각하판결은 본안심리를 거절하는 처분으로서 기판력이 본안에 미치지 않으므로, 원고에게 본안청구기각보다 불리한 결과가 아니다.

(2) 불이익변경금지의 원칙과의 관계

- 판례는 제1심의 청구기각(본안기각) 판결에 대하여 원고만이 항소한 경우, 항소심 법원이 소가 부적법함을 이유로 제1심 판결을 취소하고 소각하판결을 하더라도 불이익변경금지의 원칙에 반하지 않는다고 본다. 본안기각판결보다 소각하판결이 원고에게 더 유리하거나 최소한 동등한 위치에 있기 때문이다.

IV. 사안의 적용

1. 제1심 법원 조치의 위법성

(1) 조사 의무 위배

- 피고 乙이 소송 계속 중 부제소특약의 합의를 주장(항변)하였으므로, 제1심 법원은 본안심리에 나아가기 전에 부제소특약의 존부와 적법성 여부를 우선적으로 심리·판단해야 할 소송법상 의무가 있었다.

(2) 선순위성 위배

- 법원이 부제소특약 유무를 확인하지 않고 곧바로 채권의 시효 소멸을 이유로 기각한 조치는 소송요건심리의 선순위성을 위반한 위법한 재판이다.

## 2. 판결의 효력 및 구제 방법

### (1) 판결의 효력

- 제1심 법원이 내린 청구기각 판결은 절차적으로 위법하나 당연무효는 아니다. 적법한 상소 대상이 되므로, 甲은 항소를 통해 원심판결의 위법성을 다투어 구제받을 수 있다.

### (2) 항소심의 최종 판단

- 항소심 법원은 부제소특약의 존재를 심리하여 특약이 유효함이 인정된다면, 제1심 판결을 취소하고 소를 부적법 각하하는 판결을 내려야 한다. 이는 불이익변경금지원칙에 저촉되지 않는 적법한 하자의 시정이다.

## V. 결론

- 제1심 법원이 피고 乙의 부제소특약 주장을 심리하지 않고 곧바로 본안기각판결을 선고한 조치는 소송요건심리의 선순위성 원칙을 위반한 위법한 조치이다. 다만, 이 판결은 당연무효가 아니며 취소사유에 해당한다. 따라서 항소심 법원은 乙의 부제소특약 주장을 심리한 후 특약이 유효함이 밝혀진다면, 제1심 판결을 취소하고 소각하판결을 선고하여 제1심의 위법을 시정하여야 한다.